刑法10 筆記：不法意識與期待可能性

> 來源：刑法10 課程字幕 02:28:00 ~ 02:48:00

🕮 法條原文速查

> **§16**（法律之不知）
> 除有正當理由而無法避免者外，不得因**不知法律**而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑。
> → 不法意識欠缺：不可避免→阻卻罪責（無罪）；可避免→得減輕其刑

> **§23 但書**（防衛過當）
> 但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。
> → 期待可能性之具體化規定

> **§24 I 但書**（避難過當）
> 但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。
> → 期待可能性之具體化規定

> **§196**（行使收受之偽造貨幣罪）
> I 行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。
> II 收受後方知為偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券而仍行使，或意圖供行使之用而交付於人者，**處五百元以下罰金**。
> III 第一項之未遂犯罰之。
> → §196 II 刑度極輕＋§196 III 未遂犯僅罰第一項 → 期待可能性之考量

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「禁止錯誤與容許錯誤之區別？」	禁止錯誤＝對**分則禁止規範**的不知（不知行為犯法）；容許錯誤＝對**阻卻違法事由法律界限**的誤認（以為法律允許更多）
「容許錯誤與容許構成要件錯誤之區別？」	容許錯誤＝**誤認法律**（以為有某權利）；容許構成要件錯誤＝**誤認事實**（以為有緊急情況）
「包攝錯誤是什麼？」	知道法規存在，但**不知自己的行為符合該法規**（如放人家的鳥以為不算毀損）
「不法意識欠缺之法律效果？」	一律適用 **§16**：可避免→得減輕；不可避免→阻卻罪責（無罪）
「反面的不法意識欠缺之效果？」	與罪責**無關**，照原本犯罪事證判斷（行為本身不構成犯罪就是不構成）
「期待可能性可否作為超法規阻卻罪責事由？」	**可以**，但僅限**極端個案**（情輕法重，如癩馬脫疆案）
「誡命錯誤適用於何種犯罪？」	**不作為犯**（誡命規範＝你應該做某事）

一、不法意識

（一）概念

- 不法意識＝行為人**知不知道自己的行為違法**
- 不法意識欠缺＝行為人**不覺得自己的行為犯法**（實際犯法）
- 放在**罪責**層次檢討

（二）常見情境

- 本國人對普通刑法犯罪→**很少發生**不法意識欠缺
- 容易發生的情境：

    1. 阻卻違法事由的界限誤認
    2. 附屬刑法（行政刑法等特別法）
    3. 外國人（不熟悉本國法規）

二、不法意識欠缺的四大類型

```
不法意識欠缺
│
├── ① 禁止錯誤（直接的不法意識欠缺）
│     ├── 對分則「禁止規範」的不知
│     ├── 例：外國人來臺吸大麻，不知大麻在臺灣是毒品
│     └── 作用在：作為犯
│
├── ② 容許錯誤（間接的禁止錯誤）
│     ├── 對阻卻違法事由的「法律界限」誤認
│     ├── 例：抓到小偷後以為可以痛打一頓（以為法律賦予此權利）
│     ├── 注意：容許錯誤 ≠ 容許構成要件錯誤！
│     │     ├── 容許錯誤＝誤認「法律」（以為有某權利）
│     │     └── 容許構成要件錯誤＝誤認「事實」（以為有小偷在偷東西）
│     └── 作用在：阻卻違法事由相關
│
├── ③ 誡命錯誤
│     ├── 與禁止錯誤相反面，作用在「不作為犯」
│     ├── 誡命規範＝你**應該做**某事（如保姆應照顧嬰兒）
│     └── 例：保姆不知道自己有照顧義務
│
└── ④ 包攝錯誤
      ├── 知道法規存在，但不知自己行為**符合**該法規
      ├── 例：打開鳥籠放走別人的鳥，以為「鳥沒死不算毀損」
      ├── 例：PO 裸照以為「沒有性行為就不算猥褻」
      └── 含攝（包攝）過程出錯
```

三、不法意識欠缺的法律效果

統一適用 §16

可避免性	法律效果	判斷標準
可避免	得**減輕**其刑	行為人有能力查證卻未查（類似過失概念）
不可避免	**阻卻罪責**（無罪）	以行為人知識能力確實無法得知違法（極少見）

可避免 vs 不可避免

- **通常是可避免的**：「上網查一下不就知道了？」
- 不可避免的極端情形：
    - 專家（律師、官員）給予錯誤資訊
    - 政府網站被駭客竄改
    - 行為人不識字、無受教育、無查證能力

> 不管是禁止錯誤、容許錯誤、誡命錯誤或包攝錯誤，法律效果**都一樣走 §16**。區分這四種的實益**只在選擇題**的名詞辨別（申論題寫「不法意識欠缺，§16」即可）。

四、反面的不法意識欠缺

概念

- 行為本身**不犯法**，但行為人**以為犯法**
- 與罪責**無關**

案例

案例	行為人想法	實際	結論
男大生與 16 歲女友合意性交後自首	以為未成年就犯法	滿 16 歲合意性交→構成要件不該當	不成立犯罪（與罪責無關）
因緊急避難侵入民宅後自首	不知有緊急避難，以為犯侵入住宅罪	緊急避難阻卻違法	不成立犯罪（與罪責無關）

> 反面的不法意識欠缺不影響判決結果，行為本身不成立犯罪就是不成立犯罪。

五、期待可能性

（一）概念

- 罪責的核心概念
- 行為人處於**艱難處境**，要他不犯罪很難 → 期待可能性降低或欠缺
- **法律不強人所難**：法律只要求人民做一般人，不要求做聖人

（二）經典案例：癩馬脫韁案（Leinenfänger Fall）

事實

1. 19 世紀德國，馬車夫所駕馬匹有怪癖（喜歡用尾巴纏繞韁繩）
2. 馬車夫向僱主反映要求換馬，僱主不理
3. 馬車夫無法辭職（辭職就失去生計）
4. 硬著頭皮繼續駕駛，馬的怪癖果然發作造成車禍

分析

- 客觀上有過失（事前預見危險仍繼續）
- 但法院判**無罪**：**無期待可能性**
- 理由：無勞動保障法制下，馬車夫不可能辭職不幹，只能硬著頭皮駕駛

（三）現行法中期待可能性的具體化規定

規定	內容	期待可能性考量
§23 但書	防衛過當得減免	人在驚慌時難免手足無措、過度反應
§24 I 但書	避難過當得減免	同上
親屬間妨害司法犯罪可減免	為親屬隱匿、頂替等	親情使人難以不幫忙脫罪
§196 II	收受後方知偽造貨幣而行使→僅罰金	一般人收到假鈔不甘損失都會花掉，人性使然
§196 III	未遂犯僅罰 §196 I 之未遂	§196 II 既遂罰很輕＋未遂不罰 → 立法者體諒人性

（四）超法規阻卻罪責事由

- 可否用期待可能性作為超法規阻卻罪責事由？
- **可以**，但僅限**極端個案**
    - 真的情輕法重、判有罪判不下去的案例
    - 例：癩馬脫韁案
    - 例：家庭主婦燙衣服時接到先生命危電話，驚慌衝出忘關熨斗致火災
- 不可濫用（如同民法誠信原則不可動輒適用）

（五）實務見解：強制避難與期待可能性

- 實務認為：行為人受強暴脅迫而有生命危險 → 強制性避難 → 放在**罪責**中處理
- 即以期待可能性欠缺阻卻罪責

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§16	不知法律→可避免得減輕；不可避免免責	不法意識欠缺之法律效果
§23 但書	防衛過當得減免	期待可能性具體化
§24 I 但書	避難過當得減免	期待可能性具體化
§196 II	收受後知偽幣而行使→僅罰金	期待可能性具體化